

PDMEQ



DIREITO CONSTITUCIONAL

Aviso sobre Direitos Autorais

Caro aluno,

Este material, elaborado com muito cuidado e empenho pelo professor Breno Lenza Cardoso, é **protegido pela Legislação de Direitos Autorais** (Lei nº 9.610/1998).

Ao adquirir o curso, você tem acesso a este conteúdo para seu uso e estudo **pessoal**. Por isso, pedimos que **não compartilhe, reproduza ou distribua este material**, no todo ou em parte, sem autorização.

O **compartilhamento** ou **uso indevido** pode gerar responsabilização civil e penal, conforme previsto em lei.

Agradecemos por respeitar e valorizar o trabalho intelectual por trás deste material. Isso ajuda a manter a qualidade e a continuidade do nosso projeto educacional.

Bons estudos!

Equipe do MEQ

DIREITO CONSTITUCIONAL

Aula 1 – Constituição e Teoria Constitucional

CONSTITUIÇÃO	5
CONCEITO	5
SENTIDO SOCIOLÓGICO	5
SENTIDO POLÍTICO	5
SENTIDO JURÍDICO	6
SENTIDO CULTURALISTA	7
FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO	8
CONSTITUIÇÃO DIRIGENTE	8
OBJETO	9
CLASSIFICAÇÃO	9
QUANTO AO CONTEÚDO (CONSTITUIÇÃO MATERIAL X CONSTITUIÇÃO FORMAL)	9
QUANTO À FORMA	9
QUANTO À ORIGEM	10
QUANTO À ESTABILIDADE (OU ALTERABILIDADE OU MUTABILIDADE)	11
QUANTO À DOGMÁTICA	12
QUANTO À EXTENSÃO	12
QUANTO À FINALIDADE	12
CLASSIFICAÇÃO ONTOLÓGICA (KARL LOEWESTEIN) QUANTO À CORRESPONDÊNCIA COM A REALIDADE (CRITÉRIO ONTOLÓGICO - KARL LOEWESTEIN)	13
QUANTO AO SISTEMA	13
SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO	16
INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS	16
CONCEITO	16
PRINCÍPIOS	17
Princípio da unidade da Constituição	17
Princípio da máxima efetividade da Constituição	17
Princípio da força normativa da Constituição	17
Princípio da “concordância prática” ou da “harmonização”	18
Princípio da interpretação das leis conforme a Constituição	18
Princípio da Presunção de Constitucionalidade	18
Proporcionalidade e razoabilidade como princípios e critérios de interpretação constitucional	18
MÉTODOS	19
Método tópico-problemático (ou método da tópica)	19
Método hermenêutico-concretizador	19

Método científico-espiritual.....	19
Método normativo-estruturante	20
Método da comparação constitucional	20
VIGÊNCIA, EFICÁCIA E APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS	20
VIGÊNCIA	20
EFICÁCIA	20
APLICABILIDADE.....	21
Normas de eficácia plena	21
Normas de eficácia contida	22
Normas de Eficácia limitada	22
PODER CONSTITUINTE	23
CONCEITO	23
ESPÉCIES DE PODER CONSTITUINTE	24
Poder Constituinte Originário	24
Poder Constituinte Derivado.....	25
FENÔMENOS DE DIREITO CONSTITUCIONAL INTERTEMPORAL (RELAÇÕES DA NOVA CONSTITUIÇÃO COM O DIREITO ANTERIOR)	26
DESCONSTITUCIONALIZAÇÃO.....	27
PRORROGAÇÃO	27
RECEPÇÃO E NÃO-RECEPÇÃO	28
REPRISTINAÇÃO	29
PODER DE REFORMA.....	29
CONCEITO	29
MUTAÇÃO.....	30
CARACTERÍSTICAS	31
ESPÉCIES DE LIMITAÇÕES AO PODER DE REFORMA.....	31
PODER DE REFORMA NA CF/88 #MEQINDICA.....	32
Forma federativa de Estado	34
Voto direto, secreto, universal e periódico.....	34
A separação dos Poderes	34
Os Direitos e Garantias Individuais	34

CONSTITUIÇÃO

CONCEITO

Há diversos conceitos possíveis para “constituição”. Ela é uma palavra plurívoca justamente por admitir vários sentidos. Vejamos cada um deles:

SENTIDO SOCIOLÓGICO



Essa concepção tem como expoente Ferdinand Lassalle, quem defendeu que a Constituição escrita é apenas uma **folha de papel**. Segundo esse autor, a verdadeira Constituição de um Estado é a **soma dos fatores reais de poder**, e é ela (a soma de fatores do poder) que prevalecerá em caso de colisão com a folha de papel.

Em uma sociedade, o poder está dividido, ou seja, há vários fatores reais de poder. Se existem vários fatores de poder, também há variados atores do exercício desse poder. Como exemplo, há o poder econômico, o poder político, o poder militar, o poder da autoridade legitimada, etc. Esses atores e fatores reais de poder estão na seara social, dialogando entre si e defendendo os seus interesses e os interesses dos grupos que os apoiam. Ao atuarem na seara social, os fatores reais de poder se somam e o resultado da soma desses fatores é a verdadeira constituição.

Dessa forma, o que está escrito na constituição formal é uma mera folha de papel. Se o que está escrito corresponde à soma dos fatores reais de poder, a constituição escrita é boa e duradoura. Porém, se há uma divergência entre o que está escrito e a soma dos fatores reais de poder, **a constituição escrita irá sucumbir (não valerá); a folha será rasgada, prevalecendo a soma dos fatores reais de poder.**

Percebe-se que a concepção sociológica enfatiza a realidade concreta do poder, deslocando o foco da norma escrita para a dinâmica social efetiva. Tal perspectiva permite compreender que a estabilidade constitucional depende, em grande medida, da correspondência entre o texto formal e os fatores reais que estruturam a sociedade.

SENTIDO POLÍTICO

Essa concepção tem como principal autor Carl Schmitt. Para ele a Constituição é a decisão política fundamental do titular do poder constituinte.

O autor defende que há diferença entre o que é Constituição e o que é lei constitucional. Constituição diz respeito à decisão política fundamental, isto é, à decisão que é indispensável para fundar um Estado. Por exemplo, não se pode ter um Estado sem decidir se será um Estado federal ou unitário, se será uma república ou monarquia, ou quais serão os direitos fundamentais, ou como ocorrerá a limitação do poder, ou se o sistema de governo será presidencialista ou parlamentarista. **A matéria atinente à decisão política fundamental é Constituição, esteja ou não escrita na constituição formal.**

Nessa linha de raciocínio, a Constituição passa a ser entendida como um ato de vontade política fundamental, responsável por definir os elementos essenciais de organização do Estado. Não se trata apenas de um conjunto de normas, mas de uma decisão estruturante que estabelece as bases do ordenamento jurídico.

Por outro lado, há disposições que estão escritas na Constituição formal, mas que não dizem respeito às decisões políticas fundamentais. Essas matérias que não dizem respeito à decisão política fundamental são meras leis constitucionais, e não verdadeira Constituição.

Como exemplo, o art. 242, § 2º, da CF/88 é mera lei constitucional, pois não diz respeito a nenhuma decisão política fundamental. Esse dispositivo é constituição apenas do ponto de vista formal, uma vez que está inserido no texto da carta magna, mas não diz respeito à decisão política fundamental.

Art. 242, § 2º, CF/88. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal.

SENTIDO JURÍDICO

O expoente da concepção jurídica de Constituição foi Hans Kelsen, especialmente tratada em sua "Teoria Pura do Direito".

Para Kelsen, a Constituição possui supremacia hierárquica formal. A Constituição é o fundamento de validade das demais normas jurídicas inferiores. É norma pura, ou seja, é puro dever-ser, devendo estar dissociada de qualquer fundamento sociológico, político ou filosófico.

Kelsen, portanto, não concorda com Lassalle, sustentando não haver que se falar em fatores de poder, pois a Constituição é norma pura, hierarquicamente suprema no Direito positivo. Assim sendo,

todos devem cumpri-la. É a Constituição que prevê como as demais normas jurídicas serão realizadas pelo legislador, que este deve obedecer a Constituição e, assim, elaborar as leis como ela manda.

Para Kelsen, a Constituição pode ter dois sentidos:

- I **Sentido jurídico-positivo:** nesse sentido, a Constituição é a Constituição formal, escrita, que ocupa o ápice da pirâmide jurídico-normativa. Ela possui supremacia e é o fundamento de validade de todas as demais normas jurídicas. Para Kelsen, portanto, o sentido jurídico-positivo de Constituição significa que a constituição é o ápice da pirâmide normativa que representa o ordenamento jurídico. É a norma suprema, ou seja, superior em relação às demais normas, as quais devem obedecê-la. É a Constituição que determina como serão produzidas todas as demais normas inferiores.
- II **Sentido lógico-jurídico:** se o fundamento de validade da lei e de todas as normas inferiores é a Constituição, qual é o fundamento de validade da própria Constituição? Kelsen diz que **a constituição encontra o seu fundamento de existência e validade na norma hipotética fundamental**. É algo hipotético porque está fora do direito posto, fora do direito positivo, fora da pirâmide jurídica; e é fundamental porque é o fundamento último de validade da Constituição e, por consequência, das normas inferiores.

Na pirâmide normativa que representa o Direito posto (ordenamento jurídico), no qual a Constituição formal se encontra no ápice, a Constituição no sentido lógico-jurídico (norma hipotética fundamental) encontra-se acima do vértice piramidal (ou seja, fora da pirâmide; acima dela).

SENTIDO CULTURALISTA

Essa concepção tem como principal autor J. H. Meirelles Teixeira. Para ele, a Constituição, como uma invenção humana, é resultado da cultura e, ao mesmo tempo, interfere na cultura. Há, portanto, uma simbiose entre Constituição e cultura (por isso que o sentido culturalista). Isso dá ensejo a uma **Constituição total** como um objeto cultural que, em uma perspectiva unitária, abrange aspectos sociológicos, jurídicos, políticos, filosóficos e econômicos.

O que Meirelles Teixeira diz é que as concepções vistas até agora não são necessariamente antagônicas e não se repelem reciprocamente. Isso porque a Constituição é um objeto complexo, que possui elementos igualmente complexos e que, à luz de uma visão unitária ou total, abrange aspectos sociológicos, jurídicos, políticos, econômicos, filosóficos etc.

Assim, segundo o autor, a Constituição total é o resultado da cultura de uma sociedade em um determinado momento da história, a partir do contexto econômico, filosófico, sociológico, político etc.

A Constituição é, portanto, um objeto cultural, uma invenção humana surgida no bojo de uma determinada cultura e que interfere (e sofre interferência) dessa mesma cultura.

FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO

A teoria da força normativa da constituição tem como principal autor Konrad Hesse. Para Hesse, “a Constituição jurídica não configura apenas a expressão de uma dada realidade. Graças ao elemento normativo, ela ordena e conforma a realidade política e social”. Hesse, assim, faz uma crítica à concepção sociológica de Lassalle, que diz que a Constituição escrita é mera folha de papel e que, se não corresponde à soma dos fatores reais de poder, ela sucumbe. Assim, o que Hesse diz, com sua teoria, é que Lassalle está errado, pois a Constituição escrita não é uma mera folha de papel.

Hesse diz que a Constituição escrita pode até sucumbir diante da não correspondência aos fatores reais de poder; no entanto, essa sucumbência nem sempre irá ocorrer, pois a Constituição escrita não é uma mera folha de papel, ela tem força normativa, ela não é apenas um espelho ou expressão de uma dada realidade (isto é, dos fatores reais do poder), tendo ela, na verdade, força normativa e, assim, podendo mudar e conformar a realidade política e social.

Dessa forma, se não há equivalência entre o que está escrito e os fatores reais de poder, não necessariamente a Constituição escrita irá sucumbir, **pois ela pode, muito bem, em virtude de sua força normativa, mudar a realidade**. Mas essa mudança da realidade depende da vontade de constituição, isto é, do empenho que as pessoas têm em concretizar a constituição. Assim, quanto maior o empenho das pessoas em concretizar a constituição, maior será a sua força normativa; quanto menor for esse empenho, menor será a força normativa da constituição.

CONSTITUIÇÃO DIRIGENTE

Essa teoria tem como principal autor J. J. Gomes Canotilho. Para Canotilho, a Constituição dirige a atuação do Estado e de seus agentes, por meio de programas de ação voltados à concretização de determinados objetivos e finalidades que são estipulados pelo próprio constituinte.

A Constituição, para Canotilho, prevê finalidades, objetivos e programas de ação, principalmente no campo econômico e social, projetando uma situação ideal que o constituinte deseja que seja implementada no futuro. A Constituição, assim, dirige o futuro da sociedade e do Estado; dirige a atuação dos governantes em direção a determinados objetivos.

Trata-se de **uma Constituição típica do Estado Social**, prevendo direitos fundamentais de segunda geração (direitos sociais) e mecanismos de intervenção do Estado na economia e na sociedade.

Todos os agentes e atividades estatais (Legislativo, Executivo e Judiciário) estão vinculados ao projeto constitucional e aos objetivos políticos e econômicos da Constituição.

OBJETO

Para Canotilho, são objetos da Constituição: a disciplina dos direitos fundamentais, a organização dos poderes e a definição dos princípios e diretrizes que orientam a vida política e social do Estado.

Contudo, a definição dos objetos é variável em razão das mudanças ocorridas nas formações das Constituições.

CLASSIFICAÇÃO

Há várias classificações constitucionais possíveis. Aqui, veremos as que mais têm sido cobradas em provas de concursos.

QUANTO AO CONTEÚDO (CONSTITUIÇÃO MATERIAL X CONSTITUIÇÃO FORMAL)

Constituição em **sentido formal** é a constituição escrita. Já Constituição em **sentido material** é o conjunto de normas escritas ou costumeiras que dizem respeito às decisões que devem ser tomadas para se formar um Estado.

Assim, a Constituição em **sentido material** diz respeito à forma de organização da sociedade política, esteja ou não escrita. Independentemente de estar escrita, é matéria constitucional (o que importa é a matéria).

Já a Constituição em **sentido formal** é o que está escrito como Constituição; é o que ocupa o lugar supremo na pirâmide normativa, diga ou não respeito a matéria estritamente constitucional.

QUANTO À FORMA

Quanto à forma, a Constituição pode ser:

- I. **escrita** (também chamada de **dogmática ou instrumental**) ou
- II. **não escrita** (também chamada de **costumeira, consuetudinária ou histórica**).

A Constituição escrita pode se subdividir em Constituição codificada e Constituição não codificada. **Codificada (reduzida, unitária, orgânica)** é a Constituição escrita contida em um único texto. **Não codificada (legal, variada, inorgânica)** é a Constituição escrita contida em mais de um texto.

A CF/88, em sua origem, é codificada, mas ela vem passando por um processo de descodificação. Hoje, na realidade brasileira, existem normas escritas de nível constitucional que estão fora da carta magna. São elas:

- I. **Tratados internacionais de direitos humanos aprovados na forma do art. 5º, § 3º**, equivalentes às emendas. Exemplo disso é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007.
- II. **Normas elaboradas pelo poder de reforma que não se integram ao texto principal da CF/88**, permanecendo no bojo das emendas de forma autônoma. Por exemplo, isso se verifica na EC 32/2001, que possui texto escrito autônomo, não se inserindo na letra da CF/88.

QUANTO À ORIGEM

Por esse critério, a Constituição pode ser:

- I. Constituição **democrática** (também chamada de **promulgada ou popular**): é aquela que é fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte, como as brasileiras de 1891, 1934, 1946 e 1988.
- II. Constituição **não democrática (outorgada, imposta)**: é a que é imposta. São as chamadas cartas constitucionais, a exemplo das brasileiras de 1824, 1937, 1967. Esta última, ressalte-se, foi aprovada pelo Poder Legislativo, e não por uma Assembleia Nacional Constituinte, sendo considerada uma Constituição outorgada, embora uma espécie rara de outorga, em que há outorga pelo Executivo com aprovação pelo Legislativo. Outro exemplo é a Constituição de 1969. Esta, formalmente, foi a EC 1/69, aprovada em virtude do AI-12 de 1969.
- III. Constituição **cesarista (plebiscitária)**: é aquela, nas palavras de José Afonso da Silva, formada por um plebiscito popular, a partir de um projeto elaborado por imperador (como os plebiscitos napoleônicos) ou por um ditador (como o plebiscito feito por Pinochet, no Chile). Nesses casos, a participação popular não é democrática; não há um ambiente

democrático, posto que o objetivo do plebiscito é ratificar a vontade do exercente do poder elaborador do projeto submetido ao crivo da população.

ATENÇÃO! Aqui, em verdade, não se trata de plebiscito. Tecnicamente, é um referendo, pois a consulta popular é posterior.

- IV. Constituição **pactuada (contratual)**: segundo Paulo Bonavides, é aquela que exprime um compromisso entre duas forças políticas rivais, normalmente, entre a monarquia enfraquecida e um outro grupo que está em ascensão. Exemplo disso é o que ocorreu, segundo Bonavides, com a Constituição francesa de 1791.

QUANTO À ESTABILIDADE (OU ALTERABILIDADE OU MUTABILIDADE)

Aqui, a Constituição pode ser:

- I. **Rígida**: é aquela cuja alteração formal ocorre por um **processo distinto e mais difícil** do que o processo de elaboração da lei comum. Fazer lei (tanto ordinária quanto complementar) se dá por um processo legislativo mais fácil do que o processo de aprovação de emendas constitucionais.
- II. **Flexível**: é aquela cuja alteração ocorre pelo mesmo processo da elaboração da lei comum. Aqui, como não há diferença de procedimentos, faz-se lei da mesma forma que se faz emendas constitucionais.; Por ter um mesmo rito de formação, percebe-se que a lei muda a Constituição e, assim, desaparecem a supremacia da Constituição, a hierarquia máxima da Constituição, a necessidade de mecanismos de controle de constitucionalidade etc.
- III. **Semirrígida**: é parte rígida e parte flexível. Aquilo que é Constituição material é rígido; aquilo que é Constituição formal é flexível. Como exemplo temos a Constituição Imperial do Brasil de 1824.
- IV. **Transitoriamente flexível**: é a Constituição que é flexível por algum tempo, findo o qual, torna-se rígida (Uadi Bulos). Exemplos: Constituição de Baden de 1947 e da Irlanda de 1937, que foram flexíveis durante os três primeiros anos de vigência.
- V. **Fixa**: é aquela que nada prevê sobre sua mudança formal, sendo alterável somente pelo próprio poder originário (Kildare Gonçalves). Exemplos: Estatuto do Reino da Sardenha, de 1848; e a Carta Espanhola de 1876.
- VI. **Imutável (permanente, granítica, intocável)**: é a Constituição que se pretende eterna, fundando-se na crença de que não haveria órgão competente para proceder à sua

reforma. É uma Constituição que pode estar relacionada a fundamentos religiosos. Perceba que essa é uma classificação muito próxima da Constituição fixa.

- VII. **Super-rígida:** segundo essa classificação, trazida pelo professor Alexandre de Moraes, trata-se da Constituição que possui um núcleo imutável, que são as cláusulas pétreas.

QUANTO À DOGMÁTICA

Quanto à dogmática, a Constituição pode ser ortodoxa ou eclética.

- I. **Constituição ortodoxa:** é aquela influenciada por uma única ideologia, a exemplo da Constituição soviética de 1977.
- II. **Constituição eclética (ou compromissória):** é aquela influenciada por várias ideologias, normalmente em uma linha conciliatória, de compromisso entre várias forças políticas. Nela, há várias forças políticas que se conciliam, a exemplo da CF/88.

QUANTO À EXTENSÃO

- I. **Constituição concisa (ou curta, breve, sumária, sucinta, básica, sintética):** é a que trata somente dos princípios fundamentais e da estrutura do Estado, não descendo a minúcias, e, por conta disso, é mais estável. Exemplos: Constituição norte-americana de 1787 e Constituição brasileira de 1891 (Pinto Ferreira).
- II. **Constituição prolixa (também chamada de analítica, longa, volumosa, inchada, ampla, extensa, desenvolvida, larga, expansiva):** é a que veicula muitos temas, entrando em detalhes que poderiam ser tratados por leis comuns. Essa Constituição normalmente necessita de mudanças constantes, a exemplo da CF/88.

QUANTO À FINALIDADE

- I. **Constituição garantia (ou constituição negativa, abstencionista):** é a Constituição que busca apenas garantir liberdades e limitar o poder. Exemplo: Constituição dos EUA de 1787. Veja-se que, já que o objetivo dessa Constituição é apenas garantir liberdades e limitar o poder, ela é curta.
- II. **Constituição dirigente (ou analítica, programática):** é a que estabelece todo um projeto de Estado para o futuro. Como consequência disso, trata-se de uma Constituição longa, que precisa prever um extenso rol de dispositivos para cumprir sua finalidade. Exemplo: CF/88.

- III. **Constituição balanço:** é aquela que nem garante nem dirige nada; apenas descreve e registra a organização política estabelecida, a exemplo das Constituições soviéticas. A Constituição balanço, como se vê, é uma mera fotografia, ela é descritiva. Essa Constituição apenas diz como estão as coisas em dado momento, mas não garante nem dirige nada.

CLASSIFICAÇÃO ONTOLÓGICA (KARL LOEWESTEIN) QUANTO À CORRESPONDÊNCIA COM A REALIDADE (CRITÉRIO ONTOLÓGICO - KARL LOEWESTEIN)

Essa classificação está ligada à essência da Constituição na prática, isto é, ao “ser” Constituição, e não apenas ao texto constitucional. Para essa classificação, importa analisar a relação entre o texto da Constituição e a realidade social. Nesse contexto, a Constituição pode ser:

- I. **Constituição normativa:** é aquela em que há uma adequação entre texto e realidade; a realidade é aquilo que o texto diz que tem que ser; a Constituição domina o processo político e social, interfere na realidade e transforma a realidade. O processo político e social se amolda à Constituição e os detentores e os destinatários do poder respeitam e cumprem a Constituição.
- II. **Constituição nominal (ou nominalista):** é aquela em que não há uma adequação entre texto e realidade, havendo um descompasso entre eles. No entanto, há uma boa vontade: o processo político não se adapta à Constituição, não por não querer, mas por não conseguir. A Constituição, aqui, tem um caráter educacional e pedagógico, servindo de guia para ser alcançado no futuro, mas não se consegue implementar a constituição (exemplo: o salário mínimo, no Brasil, não consegue atender a todas as necessidades previstas no art. 7º, IV, da Constituição Brasileira de 1988).
- III. **Constituição semântica:** é aquela que está a serviço das classes dominantes. Aqui, também inexistente adequação entre texto e realidade, mas porque as classes dominantes não querem implementar a constituição. Esse tipo de Constituição trai o verdadeiro significado de Constituição, pois serve apenas às classes dominantes, às elites; Ela legitima práticas autoritárias de poder. Para Marcelo Neves, essa Constituição deve ser chamada de instrumentalista, pois é um mero instrumento do detentor de poder.

QUANTO AO SISTEMA

Nesta classificação, a Constituição pode ser:

- I. **Principiológica:** é a Constituição em que predominam princípios.
- II. **Preceitual:** é aquela em que predominam regras.

CLASSIFICAÇÃO DA CF/88	
Quanto à forma	Escrita (instrumental)
Quanto à origem	Promulgada
Quanto à estabilidade (alterabilidade ou mutabilidade)	Rígida
Quanto à dogmática	Eclética
Quanto à extensão	Analítica
Quanto à finalidade	Garantia e dirigente
Quanto à correspondência com a realidade	Normativa (pretende ser)
Quanto ao sistema	Principiológica

#JACAIU

(TRT-24ª REGIÃO 2025 - REAPLICAÇÃO – ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA – FGV) A Assembleia Constituinte do país Alfa, formada com base em critérios estritamente democráticos, procurou incorporar ao texto constitucional os valores subjacentes ao ambiente sociopolítico no momento de sua promulgação, de modo a assegurar a sua permanência e imutabilidade. Além disso, buscou individualizar as linhas gerais dos programas governamentais a serem executados no curso da vigência da nova ordem constitucional.

Considerando as características indicadas, a Constituição do país Alfa pode ser classificada como:

- a) nominal e eclética.
- b) semântica e histórica.
- c) orgânica e normativa.
- d) dogmática e dirigente.
- e) preceitual e programática.

GABARITO: D

#JACAIU

(TRT-10ª REGIÃO 2025 – TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA CESPE/CEBRASPE) Julgue o item a seguir relativo à aplicabilidade das normas constitucionais, às classificações da Constituição Federal de 1988 e aos direitos e garantias fundamentais.

No que concerne à classificação das constituições, é correto afirmar que o Brasil adotou, no ano de 1988, um modelo de Constituição eclética, baseada em uma única ideologia política.

CERTO/ERRADO

COMENTÁRIOS:

A afirmativa está **incorreta**. A CF/88 é classificado, quanto à sua dogmática, como eclética, pois é influenciada por várias ideologias.

GABARITO: ERRADO

#JACAIU

(TRT-6ª REGIÃO 2018 – ANALISTA JUDICIÁRIO – OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL FCC) É correto classificar a Constituição Federal brasileira de 1988, quanto:

- a) à origem, como outorgada, pois não foi votada e aprovada diretamente pelo povo, mas tão somente por seus representantes.
- b) à extensão, como sintética, por abordar, muitas vezes de forma minuciosa, todos os assuntos que os representantes do povo entenderam fundamentais.
- c) ao modo de elaboração, como histórica, constituída através de um lento e contínuo processo de formação ao longo do tempo.
- d) ao conteúdo, como formal, em razão de ter elegido como critério preponderante o processo de sua formação, e não o conteúdo de suas normas.
- e) à alterabilidade, como semirrígida, em razão de algumas matérias exigirem um processo de alteração mais dificultoso do que o exigido para a alteração das espécies normativas infraconstitucionais.

COMENTÁRIOS:

A opção apontada como correta foi a da letra “D”. Vejamos.

A alternativa “A” está incorreta porque a CF/88 é classificada, quanto à origem, como promulgada, por ser fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte.

A alternativa “B” está incorreta porque a CF/88 não é sintética, mas analítica. Veicula muitos temas e entra em detalhes que poderiam ser tratados por leis comuns.

A alternativa “C” está incorreta porque a CF/88 é **escrita** (também chamada de **dogmática ou instrumental**).

A alternativa “D” está correta, pois a CF/88 é classificada como formal. A Constituição em **sentido formal** é o que está escrito como Constituição, é o que ocupa o lugar supremo na pirâmide normativa, diga ou não respeito a matéria estritamente constitucional.

A alternativa “E” está incorreta, pois a CF/88 é classificada como rígida, uma vez que a sua alteração formal ocorre por um **processo distinto e mais difícil** do que o processo de elaboração da lei comum.

GABARITO: D

SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO

A supremacia da Constituição significa a superioridade da Constituição, ou seja, as normas constitucionais se encontram em um patamar superior em relação às demais normas jurídicas. Essa ideia é representada na pirâmide de Kelsen: em seu vértice, está a Constituição e, abaixo dela, aparecem as demais normas do ordenamento jurídico.

A Constituição ocupa o topo dessa pirâmide, a qual representa o ordenamento jurídico. E, por ocupar o vértice da ordem jurídica, ela serve como fundamento de validade de qualquer espécie normativa que integre essa mesma ordem jurídica. Nessa linha de raciocínio, qualquer espécie de norma do ordenamento terá a Constituição como fundamento (comum) de validade.

A Constituição, portanto, irradia-se como fundamento de validade.

INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS

CONCEITO

Primeiramente, é necessário esclarecer se **há diferença entre hermenêutica e interpretação**. Essa questão é discutida na doutrina, havendo diferentes opiniões a esse respeito.

Alguns doutrinadores entendem que hermenêutica e interpretação são expressões sinônimas. Outros entendem que não há utilidade prática alguma em diferenciá-las. Uma terceira corrente enxerga diferença de utilidade prática entre elas, ao afirmar que interpretação seria a atividade concreta de encontrar o significado da norma, ao passo que hermenêutica seria a ciência que se ocupa de estabelecer as regras abstratas (isto é, os “cânones”) que o intérprete utiliza para encontrar o significado da norma e resolver um caso concreto.

Em nossas aulas, as expressões “hermenêutica” e “interpretação” serão utilizadas como sinônimas, sem que seja feita, portanto, a diferenciação que vimos acima.

Hermenêutica constitucional é atividade intelectual de revelação do sentido, alcance e conteúdo de determinada norma constitucional (FERRARA, Francesco. *Interpretação e Aplicação das Leis*. 4ª ed. Coimbra: Arménio Amado, 1987. p. 128). Segundo a doutrina, essa é a melhor conceituação de hermenêutica constitucional.

Ora, qualquer norma tem um sentido, um alcance e um conteúdo. A atividade por meio da qual o intérprete, de modo intelectualizado, faz a revelação do sentido, alcance e conteúdo de uma norma constitucional é a, justamente, a atividade de hermenêutica constitucional.

Trata-se, como visto, de uma atividade intelectual. Por essa razão, é uma atividade humana, e não mecanizada.

A interpretação constitucional é igual a qualquer atividade que envolva interpretação. Em outras palavras, a interpretação constitucional é uma forma de interpretação jurídica; é uma forma de interpretação do direito. O que há de peculiar, aqui, é o fato de que o objeto dessa atividade é uma norma da Constituição, e não da legislação infraconstitucional. É por isso que, em regra, são aplicados a ela os métodos, as técnicas e os princípios que, geralmente, são aplicados à interpretação jurídica.

O que há de diferente na interpretação constitucional são as características peculiares das próprias normas constitucionais, quais sejam:

- Superioridade hierárquica;
- Caráter político;
- Conteúdo específico; e
- Natureza da linguagem.

✓ PRINCÍPIOS

Princípio da unidade da Constituição

A Constituição deve ser interpretada em sua globalidade, como um sistema, de modo a se afastar eventuais antinomias. Esse princípio impõe ao intérprete a análise da Constituição como um todo, buscando conciliar eventuais tensões existentes entre suas normas.

Princípio da máxima efetividade da Constituição

Quando se fala em princípio da máxima efetividade, significa que a interpretação deve conferir à norma o sentido que lhe dê maior efetividade, sendo vedada qualquer interpretação que lhe restrinja ou mesmo lhe suprima a efetividade.

Ele deve ser compreendido no sentido de ter a norma constitucional a mais ampla efetividade social, estando intimamente relacionado aos direitos fundamentais.

Princípio da força normativa da Constituição

Deve-se interpretar a Constituição de modo a dar maior efetividade e permanência às suas normas.

Esse princípio determina que o intérprete deve atribuir às normas constitucionais um sentido que lhes garanta eficácia e estabilidade, permitindo, também, sua atualização ao longo do tempo.

Ele parte da ideia de que a norma constitucional não existe de forma isolada em relação à realidade.

Princípio da “concordância prática” ou da “harmonização”

Com base na unidade da Constituição, os bens jurídicos por ela protegidos devem conviver de forma harmônica, mesmo diante de conflitos ou concorrência, evitando-se, assim, o sacrifício total de um princípio em detrimento de outro.

Princípio da interpretação das leis conforme a Constituição

Diante de normas que admitem mais de uma interpretação, deve-se adotar aquela que mais se compatibilize com a Constituição, afastando-se interpretações contrárias ao texto constitucional.

Princípio da Presunção de Constitucionalidade

Quando se fala em presunção de constitucionalidade, significa que toda norma tem presunção de validade. Contudo, essa presunção é relativa, podendo ser elidida ou convertida.

Essa presunção pode ser elidida (afastada) se houver declaração de inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo. Outrossim, a presunção relativa pode ser convertida em presunção absoluta de constitucionalidade quando declarada a constitucionalidade da lei ou do ato normativo.

Proporcionalidade e razoabilidade como princípios e critérios de interpretação constitucional

A proporcionalidade é um critério de aferição da validade de todo e qualquer ato do poder público. São 3 os vetores desse princípio:

- I. **Adequação:** significa que o meio escolhido deve ser adequado ao fim visado. Veda-se, assim, a adoção de qualquer meio que se mostre inadequado ao fim que se busca.
- II. **Necessidade:** significa que o meio escolhido deve ser necessário à obtenção do fim visado, sendo vedado, a princípio, qualquer excesso.
- III. **Proporcionalidade em sentido estrito:** mesmo sendo a medida adequada e necessária, é preciso avaliar se, ao atingir o objetivo pretendido, essa medida não impõe restrições

excessivas a outros valores constitucionais, devendo-se buscar o equilíbrio entre máxima efetividade e mínima restrição.

MÉTODOS

Os métodos de interpretação da Constituição ditam o caminho que o intérprete deve percorrer para encontrar o sentido da norma constitucional. Esses métodos foram sistematizados e agrupados pelo professor J. J. Gomes Canotilho. Vejamos cada um deles:

Método tópico-problemático (ou método da tópica)

Esse método (atribuído a Theodor Viehweg) nada mais é do que a aplicação do “método da tópica” na interpretação da Constituição.

O Tópico-Problemático é o método que dá primazia ao problema. É o método em que o intérprete parte do problema para a norma. Em outras palavras: o intérprete, em um primeiro momento, analisa o problema e define qual é a solução mais justa e adequada ao caso. Apenas depois disso, ele vai em busca do significado da norma que dê sustentação à solução encontrada.

Método hermenêutico-concretizador

Nesse método (atribuído a Konrad Hesse), o intérprete segue o caminho inverso do método Tópico-Problemático. Assim, ao seguir o método Hermenêutico-Concretizador, o intérprete parte da norma para o problema, ou seja, em um primeiro momento, ele busca o significado da norma e, depois, define qual solução deve ser dada ao problema apresentado com base no sentido da norma aplicável.

Para isso, o intérprete se vale de suas pré-compreensões da realidade social e do próprio problema apresentado, realizando um círculo hermenêutico (vai-e-vem) entre o contexto em que se encontra e o texto da norma.

Método científico-espiritual

Esse método (atribuído a Rudolf Smend) leva em consideração que a Constituição, assim como o próprio Estado, é um fenômeno cultural ligado aos valores da sociedade. Por conta disso, a Constituição funciona como instrumento de integração da comunidade, além de ser dinâmica e constantemente renovada, já que os valores sociais mudam conforme o contexto histórico.

Assim, na interpretação constitucional, para encontrar o significado da norma, o intérprete deve considerar a realidade social e os valores (espíritos) da sociedade e da própria Constituição. Ele deve se colocar como um membro da comunidade, para, levando em conta os valores a ela inerentes, realizar a interpretação constitucional.

Método normativo-estruturante

Segundo esse método (atribuído a Friedrich Müller), apenas existe norma concretizada. Interpretar a norma é concretizá-la, aplicando-a ao caso concreto.

Aqui, para interpretar – e concretizar – a norma, o intérprete deve se valer do texto normativo e do seu âmbito de incidência (situação “normada”). É do encontro do texto com seu âmbito de incidência que se identifica a norma geral, a qual, ao ser aplicada ao caso concreto, é concretizada.

Mas é importante registrar que, segundo esse método, o texto normativo é apenas a “ponta do iceberg”, significando isso que não é apenas o texto que o intérprete deve levar em consideração, mas, também, o ordenamento jurídico como um todo, as lições doutrinárias, os artigos científicos, as obras acadêmicas, a jurisprudência etc.

Método da comparação constitucional

Esse método estabelece que a interpretação é feita mediante a comparação dos diversos ordenamentos constitucionais, sendo ele oriundo da doutrina de Peter Häberle, que defende o comparativismo como um quinto método de interpretação, ao lado dos 4 métodos interpretativos da hermenêutica clássica desenvolvidos por Savigny (gramatical, lógico, histórico e sistemático).

O método da Comparação Constitucional, portanto, é o comparatismo aplicado à hermenêutica constitucional.

VIGÊNCIA, EFICÁCIA E APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS.

VIGÊNCIA

Vigência, no Direito Constitucional, significa a própria **existência da norma**. Assim, se a norma existe, possui vigência; se ela não existe, não possui vigência. Não se leva em conta se a norma é compatível com outra, nem tampouco se pode ser aplicada, mas apenas se ela existe.

EFICÁCIA

Eficácia é a aptidão da norma jurídica para a produção dos efeitos que lhe são próprios, dos efeitos que dela são esperados. A eficácia está intimamente ligada ao conceito de vacância da lei (*vacatio legis* e *vacatio constitucionalis*).

A *vacatio* é o intervalo de tempo durante o qual a norma possui vigência, presume-se válida, mas ainda não tem eficácia.

Ultrapassada a *vacatio*, passa-se a ter uma norma com vigência, com presunção de validade e com eficácia, ou seja, plenamente apta a produzir efeitos jurídicos.

Diante disso, o termo inicial de eficácia da norma é, no mínimo, a publicação da norma. Diz-se “no mínimo”, porque tudo depende de a norma ter *vacatio* ou não: se não houver *vacatio*, o termo inicial da eficácia será a publicação; se houver *vacatio*, o termo inicial da eficácia será a data de publicação acrescida da *vacatio*.

Quando um dispositivo diz que a lei entra em vigor em determinada data, leia-se que ela passa a ter eficácia (ou torna-se eficaz) a partir dessa data.

APLICABILIDADE

Segundo José Afonso da Silva, aplicabilidade é **a qualidade da norma de poder ser aplicada a casos concretos**.

Diante desse conceito, percebe-se que não se pode falar em aplicabilidade ou não de uma norma sem haver um caso concreto. O intérprete deve enfrentar um caso concreto para dizer se a norma tem aplicabilidade ou não, mesmo porque aplicabilidade é um conceito ligado à subsunção da norma ao caso.

Acerca da aplicabilidade, a doutrina moderna classifica as normas constitucionais em 3 (três) tipos: normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada.

Normas de eficácia plena



São aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição, já produzem todos os seus efeitos, independentemente de regulamentação.

As normas constitucionais de **eficácia plena**, dessa forma, possuem aplicabilidade direta, integral e imediata.

A aplicabilidade **direta** significa que a norma constitucional pode ser aplicada a casos concretos, independentemente da produção de norma integrativa.

A aplicabilidade **integral** significa que a norma constitucional não admite contenção de eficácia. Assim, na norma de eficácia plena, a contenção de eficácia não é juridicamente aceita. Em outras palavras, ela exerce plenamente tudo o que prevê.

E a aplicabilidade **imediate** significa que a norma constitucional pode ser aplicada a casos concretos desde o momento de sua produção. Portanto, produz efeitos desde logo.

Normas de eficácia contida



Também têm aplicação imediate e direta, produzindo efeitos desde a promulgação da Constituição. No entanto, podem sofrer restrições posteriores.

Dessa forma, tem aplicabilidade **não integral**, pois sujeita-se a limitações.

Tais limitações (restrições) podem decorrer tanto de lei infraconstitucional, quanto da própria Constituição. Como exemplo de restrição decorrente da própria Constituição, temos as limitações impostas durante o estado de sítio.

Caso não exista uma limitação, a norma opera com eficácia plena.

Normas de Eficácia limitada



São as que dependem de regulamentação para produzirem plenamente os seus efeitos. Possuem aplicabilidade mediata, pois têm sua eficácia diferida (postergada); **indireta**, pois necessitam de norma posterior para incidência completa; e **reduzida**, uma vez que, enquanto não regulamentadas, têm alcance restrito.

No entanto, mesmo que sem regulamentação, as normas constitucionais de eficácia limitada já produzem efeitos relevantes, como:

- I. Revogam normas anteriores incompatíveis;
- II. Impedem a edição de leis em sentido contrário e
- III. Servem como parâmetro interpretativo.

As normas de eficácia limitada subdividem-se em:

- I. Princípios institutivos ou organizativos: são as normas que preveem a criação ou estruturação de órgãos e instituições, a serem realizadas por lei.
- II. Princípios programáticos: são as normas que estabelecem diretrizes e objetivos a serem concretizados pelo Poder Público. São, em regra, identificadas por verbos no futuro, pois estes, embora não sejam um indicativo claro de um programa, são indícios de um programa de atuação do governo a ser futuramente colocado em prática. É o caso, por

exemplo, do art. 201 da CF/88, o qual só adquiriu aplicabilidade com a edição das Leis nº 8.212 e 8.212, ambas de 1991.

PODER CONSTITUINTE

CONCEITO

É o poder capaz de criar (elaborar) uma nova Constituição; é o poder que estabelece os fundamentos da organização da sociedade; É o poder capaz de estruturar e organizar o Estado por meio de uma Constituição, definindo seus princípios regentes, os direitos fundamentais dos cidadãos, os poderes e limites estatais e a competência das entidades, órgãos e instituições que o compõem.

Quem são os atores do poder constituinte? Isto é, quem são os sujeitos que atuam no poder constituinte? **Há dois atores**, a saber:

- O **titular** do poder constituinte; e
- O **exercente** do poder constituinte, que pode ser alguém **eleito** para exercer o poder constituinte (e, aí, tem-se a figura da assembleia constituinte) ou alguém **não eleito**.

Há duas espécies de Assembleia Nacional Constituinte:

- 1) **Soberana**: é aquela que trabalha sem qualquer limitação; que não tem sua atuação restringida por plebiscito ou referendo; e
- 2) **Não soberana**: é aquela que trabalha com limites demarcados por plebiscito ou que se sujeita a um referendo para validar o resultado da sua obra. Isso é possível porque **o titular do poder constituinte é o povo**.

É pelo **plebiscito** que o povo pode, enquanto titular do poder constituinte, definir e delimitar as matérias que serão objeto da atuação da Assembleia Nacional Constituinte, a qual exercerá o poder constituinte. Um plebiscito pode definir, por exemplo, um novo sistema de governo a ser instituído, como o parlamentarismo. Já pelo **referendo**, a lei constitucional é submetida à aprovação ou rejeição do povo. Ou seja, por meio do referendo, o povo, enquanto titular do poder constituinte, dará a palavra final sobre a validade, e própria existência, de uma norma constitucional.

A Assembleia Nacional Constituinte brasileira de 1987/1988 foi uma Assembleia foi soberana, pois não sofreu limitação decorrente de plebiscito, nem teve seu resultado submetido a referendo.

Por fim, o exercente **não eleito** pode ser: I) um ditador; II) um revolucionário; III) uma comissão de “notáveis” etc.

ESPÉCIES DE PODER CONSTITUINTE

Dentro de uma visão clássica, o poder constituinte pode ser dividido em duas espécies:

- I. **Poder Constituinte Originário** (também chamado de **inicial, inaugural, de primeiro grau**): é aquele que dá origem a uma nova Constituição.
- II. **Poder Constituinte Derivado** (também chamado de **secundário, de segundo grau**): é aquele capaz de alterar ou complementar a Constituição.

Poder Constituinte Originário

Como dito, ele é o poder que dá origem a uma nova Constituição.

Para a teoria do poder constituinte, o chamado poder constituinte originário tem 3 (três) características, sendo ele:

- I. **Inicial**: ele é inicial porque inicia o direito positivo, dando origem à Constituição. Ele é, então, o início de tudo, nada havendo acima dele. Não há, em grau de hierarquia, nenhuma outra ordem jurídica que lhe seja superior.
- II. **Autônomo**: ele é autônomo porque não convive em mesmo grau com nenhum outro poder jurídico. Não existe um poder jurídico de mesma hierarquia que a do poder constituinte originário. Daí, sua autonomia.
- III. **Incondicionado**: como o poder constituinte originário não convive com nenhum outro poder jurídico de mesma ou superior posição, ele não está limitado, em termos jurídicos, pelo direito positivo anterior.

Assim, nenhuma norma anterior pode ser oposta ao poder constituinte originário, que atua correlatamente ao poder de desconstituir, ao poder de apagar tudo do sistema jurídico anterior.

O poder constituinte originário não está preso a direito adquirido, a ato jurídico perfeito ou a coisa julgada. Esses institutos servem para limitar o poder de reforma, mas não o poder constituinte originário, que – repita-se – não está sujeito a limites jurídicos.

A falta de limites jurídicos ao poder constituinte originário tornaria possível, por exemplo, o retorno da escravidão, ou mesmo o fim do direito ao voto pelas mulheres, ou, ainda, a admissão execuções sumárias sem observância do devido processo legal, dentre outras aberrações?

NÃO! Isso não é possível.

A razão dessa impossibilidade, segundo Canotilho, é que, embora o Poder Constituinte Originário seja juridicamente ilimitado, ele não é exercido em um vazio, em um vácuo histórico-

cultural. Ele será exercido por uma Assembleia Nacional Constituinte ou por alguém não eleito, mas sempre dentro de um contexto histórico-cultural, no qual é necessário reconhecer a existência de limites de outra natureza que não jurídica. São os chamados limites metajurídicos (ou extrajurídicos) do poder constituinte, os quais são veiculados por meio de pressões de grupos sociais, econômicos, religiosos, políticos etc. Os limites metajurídicos, assim, são impostos pela realidade social, cultural, econômica e política de um determinado Estado que se encontra em processo de elaboração de uma nova Constituição.

Poder Constituinte Derivado

Ele é o poder capaz de alterar ou complementar a Constituição. Subdivide-se em:

- a) **Poder Constituinte Derivado Reformador**, que é aquele que dá origem a uma modificação/reforma na Constituição já existente, manifestando-se por meio de Emendas Constitucionais. Perceba que este é um poder derivado exercido em caráter permanente, fazendo com que a Constituição acompanhe a se adapte às mudanças sociais.
- b) **Poder Constituinte Derivado Revisor**, é atípico e exercido uma única vez, sem o caráter de permanência que é singular ao poder constituinte derivado reformador. Ocorreu, por exemplo, quando foi feita a revisão na CF/88, que já estava prevista no art. 3º do ADCT. Essa revisão da CF/88 foi expressamente prevista para ser realizada 05 (cinco) anos após a promulgação da CF/88, em um procedimento mais simplificado do que o de aprovação de uma Emenda Constitucional. Naquela ocasião, exigiu-se, apenas, maioria absoluta e sessão unicameral do Congresso Nacional para a aprovação da matéria constitucional revisada. Do exercício desse poder constituinte derivado revisor, decorreram 06 (seis) Emendas Constitucionais de Revisão. Segundo o STF, esse poder não pode mais ser exercido, por se tratar de norma constitucional de eficácia exaurida. Assim, nem mesmo pela introdução de uma norma autorizativa, por meio de Emenda Constitucional, ele poderia ser novamente exercido. Ocorreu uma única vez, para nunca mais; e
- c) **Poder Constituinte Derivado Decorrente**, que é aquele que dá ensejo à criação das Constituições dos Estados-Membros. Ele pode ser subdividido em **duas espécies**:
 - poder constituinte derivado decorrente inicial, que é o poder que cria as Constituições Estaduais; e

- poder constituinte derivado **decorrente de revisão**, que é o poder que altera as Constituições Estaduais por meio de emendas constitucionais estaduais.

E o poder constituinte decorrente também se manifesta na elaboração da Lei Orgânica do DF e na elaboração das Leis Orgânicas dos Municípios?

Quanto à Lei Orgânica do Distrito Federal, o **STF** entende que ele se aproxima mais dos Estados do que dos Municípios (ADI 3756). Isto é, o DF parece mais com os Estados do que com os Municípios. Além disso, a Lei Orgânica do DF possui uma natureza de verdadeira Constituição, podendo, inclusive, ser paradigma de controle de constitucionalidade distrital (RE 577.025). Isso ocorre porque ela deriva diretamente da Constituição Federal. Por isso, a doutrina predominante e o STF entendem que **a LODF é manifestação do poder constituinte decorrente**.

Em relação aos Municípios, as suas **Leis Orgânicas** devem obedecer não apenas à CF, mas também às Constituições estaduais. Elas não derivam diretamente da Constituição Federal, tratando-se de norma elaborada por um poder de **terceiro grau**, além de **não servirem como** parâmetro de controle de constitucionalidade. Essa afirmação justifica o fato de que eventual choque entre a Lei Orgânica municipal e a lei municipal não se sujeita a um controle de constitucionalidade, **mas de legalidade**. Por esses motivos, a doutrina majoritária entende que **Lei Orgânica municipal não é manifestação do poder constituinte decorrente**.

FENÔMENOS DE DIREITO CONSTITUCIONAL INTERTEMPORAL (RELAÇÕES DA NOVA CONSTITUIÇÃO COM O DIREITO ANTERIOR)

Positivada a nova Constituição, o que ocorre com a Constituição anterior e com a legislação anterior? É nesse contexto que surgem os fenômenos de direito constitucional intertemporal, no qual se pode vislumbrar a existência de dois grandes grupos:

- I. Relações da nova Constituição para com a **CONSTITUIÇÃO ANTERIOR**. Aqui, ocorrem os seguintes fenômenos:
 - Desconstitucionalização; e
 - Prorrogação (também chamada de “recepção material de normas constitucionais anteriores”).

II. Relações da nova Constituição para com a **LEGISLAÇÃO ANTERIOR**. Aqui, ocorrem os seguintes fenômenos

- Recepção e não-recepção; e
- Repristinação.

Vejamos cada um deles:

DESCONSTITUCIONALIZAÇÃO

Surgindo uma nova constituição, o que ocorre com a Constituição anterior? **A regra é que a constituição antiga seja integralmente revogada pela nova.** Ou seja, com o advento de uma nova, a Constituição anterior é jogada fora; é retirada do direito positivo.

A desconstitucionalização é uma exceção a essa regra: na desconstitucionalização, a nova ordem constitucional (inaugurada com a nova constituição) recebe disposições da Constituição anterior (que, antes da nova constituição, eram constitucionais), porém com *status* de lei ordinária. Assim, essas antigas normas constitucionais perdem *status* constitucional, sendo algumas delas recebidas pela nova ordem constitucional em grau hierárquico inferior no direito positivo, passando a ter status de mera lei ordinária.

A desconstitucionalização não é um fenômeno automático. Ela **exige previsão expressa na nova Constituição**, em especial, no bojo do ADCT da nova Constituição.

A desconstitucionalização pode ser útil, especialmente se a constituição anterior, que se pretende substituir, for prolixa (mais longa) do que a nova (mais sintética). Nesse caso, para evitar um vazio legislativo, algumas normas da constituição anterior podem ser utilizadas no novo ordenamento constitucional.

PRORROGAÇÃO

Também chamada de recepção material de normas constitucionais anteriores.

Esse fenômeno diz respeito à aplicação temporária ou definitiva de dispositivos da constituição anterior, que continuam com *status* constitucional na nova ordem constitucional. **Esse fenômeno também demanda previsão expressa.** Como exemplo:

Art. 34, ADCT. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido, até então, o da

Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda nº 1, de 1969, e pelas posteriores.

RECEPÇÃO E NÃO-RECEPÇÃO

Esse fenômeno diz respeito às relações da nova constituição com a legislação infraconstitucional anterior. Isto é, ele diz o que ocorre com as leis quando surge uma nova Constituição.

A **recepção** é o fenômeno pelo qual uma nova Constituição ou uma nova emenda constitucional recebe como válidas as normas infraconstitucionais anteriores que forem materialmente compatíveis com o novo texto constitucional.

Já a **não-recepção** é o fenômeno inverso, pelo qual as normas infraconstitucionais anteriores que não forem materialmente compatíveis com a nova constituição ou com a nova emenda constitucional, são descartadas.

Para o STF, a não-recepção equivale a uma revogação da norma infraconstitucional. Na doutrina, porém, há quem prefira não falar em revogação nesse caso porque, tecnicamente, o que se tem na revogação é uma norma posterior revogando norma anterior de mesma hierarquia. Já na não-recepção (que envolve Constituição ou emenda constitucional), tem-se uma norma constitucional, de hierarquia superior, retirando a norma infraconstitucional anterior do ordenamento jurídico. De todo modo, para o STF diz que não-recepção e revogação são a mesma coisa.

A **incompatibilidade que pode provocar a não-recepção é a incompatibilidade material**, de conteúdo propriamente dito, e não a incompatibilidade formal. Exemplo: a CF/88 deixou de prever o Decreto-Lei como uma espécie normativa existente em nosso ordenamento jurídico. Isso significa que todos os Decretos-Leis anteriores, editados nos moldes da Constituição anterior, foram revogados? Não, porque o que importa não é a compatibilidade formal, mas sim a compatibilidade material com a nova Constituição. Assim, se o conteúdo material do Decreto-Lei é compatível com a CF/88, ele é mantido no ordenamento jurídico, mas se o seu conteúdo não é compatível com a CF/88, ele não será recepcionado. Tanto é assim que, até hoje, ainda temos muitos Decretos-Leis em vigor, a exemplo do Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940).

Assim, se uma norma é editada sob a forma válida e essa forma passa a não mais existir por força de uma nova Constituição ou de uma emenda constitucional, isso não irá impedir a aplicação da norma, desde que ela seja materialmente compatível com a nova ordem constitucional.

Por outro lado, a norma infraconstitucional que é recepcionada pela nova Constituição ou pela nova emenda constitucional, por ter conteúdo compatível com a nova ordem constitucional, passa a ter *status* da espécie normativa que a nova ordem constitucional prevê como o meio adequado para

tratar da matéria. Por exemplo, o Código Penal foi editado sob a forma de Decreto-Lei (Decreto-Lei 2.848/1940) e, por ter conteúdo compatível com a CF/88, foi recepcionado pela CF/88, mas passou a ter *status* de lei ordinária (que é a espécie normativa estabelecida na CF/88 para tratar de direito penal).

Note, ainda, que recepção e não-recepção são fenômenos **automáticos e implícitos**. Assim, não dependem de previsão expressa na nova Constituição ou emenda constitucional.

REPRISTINAÇÃO

É o fenômeno pelo qual uma norma infraconstitucional que não havia sido recepcionada por uma Constituição – e que, portanto, havia sido revogada – restaura-se e volta ao ordenamento por força de uma outra nova Constituição.

A repristinação **não é um fenômeno automático, não é implícito, nem presumido, demandando previsão expressa**. Sendo assim, no silêncio, não há que se falar em repristinação de leis anteriores.

Exemplo: havia uma Constituição que previa a pena de morte, sob a égide da qual foi editada uma lei ordinária disciplinando a execução da pena de morte. Depois, sobreveio uma nova Constituição, que acabou com a pena de morte. Então, a lei que disciplinava a execução da pena de morte acabou por não ser recepcionada pela nova Constituição e, assim, foi revogada. Tempos depois, uma terceira Constituição vem a ser promulgada, restabelecendo a pena de morte. Abre-se, assim, a possibilidade de repristinação daquela lei que, antes, disciplinava a execução da pena de morte, desde que contida, na nova Constituição, previsão expressa nesse sentido. **Obs.** o princípio da vedação ao retrocesso foi desconsiderado nesse exemplo.

PODER DE REFORMA

CONCEITO

É o poder de direito destinado a **alterar** formalmente a constituição. Note-se que é um poder de direito porque é constituído, ou seja, que tem fundamento na própria constituição.

O poder de reforma, assim, é um poder de direito que tem como objetivo realizar mudanças na própria constituição. É um mecanismo de abertura da constituição para novos interesses e necessidades, pois a constituição não pode ser algo fechado no tempo. Ela não pode ser hermética, devendo acompanhar a evolução da sociedade. É nesse contexto que se torna necessário o poder de reforma.

As mudanças na constituição podem ocorrer por meio de mecanismos ligados a processos formais ou a processos informais de mudança.

Nos **PROCESSOS FORMAIS** ocorre alteração formal da constituição. Por meio deles, o texto da constituição é modificado. São três os processos formais de mudança constitucional:

- I. emenda constitucional;
- II. revisão constitucional; e
- III. no caso do Brasil, a aprovação de tratados internacionais sobre direitos humanos.

Por outro lado, o **PROCESSO INFORMAL** de mudança é a mutação, que pode ser constitucional ou inconstitucional.

MUTAÇÃO

A mutação é um processo informal (ou não formal) de mudança da Constituição provocado pela alteração da tradição, dos costumes, da interpretação doutrinária ou, especialmente, da interpretação jurisprudencial, com destaque para a interpretação feita pela Corte Constitucional.

Na mutação, há uma espécie de dissociação entre o texto e a norma. Como se sabe, norma é o resultado da interpretação do texto; uma não se confundindo com o outro. Assim, a mutação ocorre da seguinte forma: **embora o texto continue a dizer exatamente o que dizia antes, não havendo mudança formal, a norma resultante da sua interpretação muda. Ou seja, a norma dizia uma coisa e passa a dizer outra.**

Portanto, na mutação, a mudança não é formal; não é no texto, mas sim no significado, no sentido das normas que resultam da interpretação do texto constitucional, o qual permanece intocado.

Há duas espécies de mutações: as mutações **constitucionais** e as mutações **inconstitucionais**.

Na **mutação constitucional**, tem-se mudança que ocorre sem ofensa absoluta à literalidade do texto ou ao espírito da Constituição. Assim, o texto permanece o mesmo, a interpretação dele muda, mas essa mudança não tem problema algum com a literalidade do texto nem tampouco com o espírito da Constituição, que se compatibilizam com a nova interpretação.

Já as **mutações inconstitucionais** são aquelas que ocorrem a partir dos denominados processos manifestamente inconstitucionais. Nesse caso, a interpretação nova ofende a literalidade do texto constitucional ou o espírito da Constituição ou mesmo ultrapassa limites de forma ou de fundo –

matéria em si – estabelecidos na Constituição. Assim, na mutação inconstitucional, tem-se uma nova interpretação, cujo resultado colide com a literalidade ou com o espírito da Constituição.

Quanto à mutação inconstitucional, tem-se, como exemplo, o caso do art. 52, X, da CF/88. Esse dispositivo prevê caber ao Senado Federal suspender a execução de lei declarada inconstitucional em sede de controle difuso de constitucionalidade. Contudo, o Ministro Gilmar Mendes sustentou que houve uma mutação e que essa participação do Senado seria dispensável, tendo efeitos meramente de publicidade. Em um primeiro momento, essa mutação foi rejeitada pelo **Supremo Tribunal Federal** (Rcl 4335), por se entender que ela conflitaria com o texto da Constituição. No entanto, superando esse entendimento inicial, o **STF**, no final do ano de 2017, passou a entender haver ocorrido a mutação do art. 52, X, da CF/88, atribuindo à resolução do Senado Federal prevista nesse dispositivo efeitos de mera publicidade (ADIs 3470 e 3406).

CARACTERÍSTICAS

O Poder Constituinte Originário, como vimos, é inicial, autônomo e incondicionado. Já o Poder de Reforma tem características distintas, quais sejam:

- i. **Derivado:** o poder de reforma é derivado porque ele tem fundamento na própria constituição, ou seja, dela deriva.
- ii. **Subordinado:** é subordinado porque tem se encontra em um nível hierarquicamente abaixo do Poder Constituinte Originário.
- iii. **Condicionado (limitado):** é limitado porque a Constituição, ao criar o poder de reforma, faz isso impondo-lhe limites.

ESPÉCIES DE LIMITAÇÕES AO PODER DE REFORMA

São quatro os limites ao poder de reforma. Vejamos:

- i. **Temporais:** são as limitações ligadas ao tempo. Na CF/88, não há limitações temporais em relação ao poder de reforma, mas existiu em relação ao poder de revisão que já mencionamos.
- ii. **Circunstanciais:** são as limitações ligadas a determinadas circunstâncias fáticas, as quais, se ocorrerem, impedem o exercício do poder de reforma.
- iii. **Formais:** são as limitações ligadas à forma, ao procedimento de alteração da constituição. Exemplo: quórum, iniciativa, dentre outras.

- iv. **Materiais:** são as limitações que dizem respeito a determinados conteúdos previstos na constituição, os quais não podem sofrer alterações. Denominam-se **cláusulas pétreas**, que podem ser explícitas ou implícitas, e que impedem a modificação de determinadas matérias pelo poder reformador.

PODER DE REFORMA NA CF/88 #MEQINDICA

O poder de reforma, como já vimos, é o poder capaz de alterar formalmente a Constituição por meio das emendas constitucionais.

O art. 59, I, da CF/88 estabelece que o processo legislativo compreende a elaboração de emendas. Como se vê, a elaboração de emendas encontra-se, no texto constitucional, localizada dentro do tópico Poder Legislativo, que é um poder constituído. Logo, o poder de reforma é um poder constituído.

O art. 60 da CF/88 dispõe sobre a iniciativa da proposta de emenda. Vejamos:

Art. 60, CF/88. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

- I - De um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
- II - Do Presidente da República;
- III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

Note que essas **regras de iniciativa** consubstanciam uma limitação formal ao poder de reforma, pois a deflagração das emendas constitucionais só pode se dar nessas três hipóteses.

O art. 60, § 1º, da CF/88 dispõe o seguinte:

Art. 60, § 1º, CF/88 - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

O que o dispositivo acima traz são limitações circunstanciais, que se justificam por se referirem a situações fáticas de instabilidade institucional, nas quais os ânimos se alteram. Por essa razão, veda-se a alteração formal da Constituição nessas ocasiões.

O § 2º do art. 60 da CF/88 traz uma limitação formal, mais precisamente quanto ao quórum de aprovação da emenda constitucional. Vejamos:

Art. 60, § 2º, CF/88 - A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

Esse dispositivo trata da **rigidez constitucional**. Perceba que é mais difícil elaborar emendas do que elaborar leis.

Note, ainda, que esses requisitos (ou limitações) buscam atingir um equilíbrio entre a necessidade de a constituição perdurar e a necessidade de a constituição mudar para satisfazer os novos interesses e necessidades da sociedade, que são dinâmicos.

O § 4º do art. 60 da CF/88 traz **limitações materiais** ao poder de reforma, elencando, assim, de forma expressa, as chamadas cláusulas pétreas. Vejamos:

Art. 60, § 4º, CF/88 - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

- I - a forma federativa de Estado;
- II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
- III - a separação dos Poderes;
- IV - os direitos e garantias individuais.

Note que esse dispositivo veicula preceitos fundamentais e princípios de hermenêutica constitucional. Isso, porém, não significa que ela é uma norma de hierarquia superior às demais normas constitucionais. Não se admite, no Brasil, hierarquia entre normas constitucionais originárias, sendo todas elas de mesma hierarquia, ainda que se esteja falando de cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas, então, estão em um mesmo nível hierárquico das demais normas constitucionais.

Qual é o real alcance desse rol de cláusulas pétreas? **O STF já decidiu que a proteção jurídica da cláusula pétrea diz respeito ao núcleo essencial das matérias descritas no rol do art. 60, § 4º, da CF/88**, não significando, portanto, uma intangibilidade absoluta e literal. O que está protegido é o núcleo essencial, e não toda e qualquer coisa que disser respeito às cláusulas pétreas. Assim foi decidido pelo STF, por exemplo, na ADI 2024-MC e no MS 23047.

Vejamos, agora, cada uma das cláusulas pétreas.

Forma federativa de Estado

A forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea. A federação não pode ser abandonada por meio de emenda constitucional.

Veja que o que está petrificado quanto à federação não são os pormenores relativos a ela, mas sim o núcleo essencial. Os pormenores, então, podem ser alterados. É possível realizar mudanças pontuais, por exemplo, nas competências legislativas da União, dos Estados e dos Municípios, transferindo competências de uma dessas esferas políticas para outra. O que não se admite é esvaziar completamente as competências de uma esfera e as atribuir a outra esfera.

Voto direto, secreto, universal e periódico

Também é cláusula pétrea o voto direto, secreto, universal e periódico.

O voto obrigatório não está incluído nessa cláusula pétrea, de modo que é possível, um dia, que seja adotado o voto facultativo, por meio de emenda constitucional.

Outro detalhe é que a periodicidade do voto é cláusula pétrea. Perceba que isso, indiretamente, protege a forma republicana de governo. Como a república significa a assunção temporária e eletiva do poder, a previsão do voto periódico acaba protegendo a república indiretamente.

A separação dos Poderes

Mais uma vez, não são os pormenores que estão protegidos por essa cláusula pétrea. Assim, é só o núcleo essencial da separação dos Poderes que recebe a proteção.

Por exemplo, a EC 45/04 criou a súmula vinculante e o efeito vinculante das decisões do STF em sede de controle de constitucionalidade abstrato. Essas vinculações se referem aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública de todas as esferas da Federação, atingindo diretamente o Poder Executivo. Ou seja, uma emenda constitucional vinculou o Poder Executivo às deliberações do STF, mas, mesmo assim, o STF entendeu que não houve violação à cláusula pétrea da separação dos Poderes, por não se ter atingido o núcleo essencial dessa cláusula pétrea.

Os Direitos e Garantias Individuais

Essa é a cláusula pétrea mais debatida de todas.

Qual é o seu real alcance? Em decorrência desse questionamento, surgiram correntes doutrinárias distintas a respeito da interpretação que deve ser dada à expressão “direitos e garantias individuais”:

- I. **Corrente restritiva (ou literal):** entende que a interpretação deve ser literal, de modo que o que está protegido é apenas o conjunto de **direitos e garantias individuais**. Logo, direitos coletivos, sociais, difusos etc. ficam de fora.
- II. **Corrente ampliativa:** entende que o que está protegido por essa cláusula pétrea é todo o rol de **direitos fundamentais**.

Ressalte-se que há uma divisão dentro da corrente ampliativa. Parte de seus defensores entende que essa cláusula pétrea abrange os direitos fundamentais **sob o ponto de vista formal**, isto é, abrangendo todos os direitos fundamentais que estão listados na Constituição. Outra parte de seus defensores diz que a proteção alcança apenas os direitos fundamentais **sob o ponto de vista material**, isto é, abrangendo somente os direitos fundamentais que têm vinculação direta com a dignidade da pessoa humana. Assim, para essa última corrente, se um direito fundamental não estiver relacionado à dignidade da pessoa humana, não será cláusula pétrea.

Pergunta-se: **somente o que está previsto no art. 5º da CF/88 está protegido pela cláusula pétrea dos direitos e garantias individuais?** Evidentemente, **não**. Na verdade, há direitos e garantias individuais fora do art. 5º da CF/88, sendo também eles protegidos pela cláusula pétrea em questão. Nesse sentido, o **STF** já reconheceu que certos direitos do contribuinte, previstos no art. 150 da CF/88, são direitos/garantias individuais, estando protegidos pela cláusula pétrea em questão (ADI 939, julgada em 1993).

Portanto, há cláusulas pétreas fora do art. 5º da CF/88.

Mas tudo que está no art. 5º da CF/88 é cláusula pétrea? Isso dependerá da corrente interpretativa (restritiva ou ampliativa) que se adotar.

Assim, se for adotada a **interpretação restritiva/literal**, segundo a qual a cláusula pétrea diz respeito apenas aos direitos e garantias individuais, nem tudo que está no art. 5º será cláusula pétrea. Isso porque o art. 5º trata de direitos e garantias individuais e coletivos e, sob o entendimento dessa corrente, não seriam cláusulas pétreas os direitos e garantias coletivos.

Por outro lado, se for adotada a **interpretação ampliativa formal**, tudo que está no art. 5º da CF/88 será cláusula pétrea. A propósito, por essa corrente interpretativa, tudo o que está no Título II da CF/88, por ser direito fundamental, será cláusula pétrea.

Por fim, se adotada a **interpretação ampliativa material**, nem tudo o que está no art. 5º será cláusula pétrea. Por exemplo, o inciso XXIX do art. 5º não será cláusula pétrea, por não ter vinculação direta com a dignidade da pessoa humana. Para essa corrente interpretativa, repise-se, só seria cláusula pétrea o direito fundamental que guardar relação com a dignidade da pessoa humana.

A interpretação ampliativa MATERIAL é a que predomina na doutrina brasileira.